

1500079-79.2018.8.26.0613

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Comarca: Tambaú

Foro: Foro de Tambaú

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

INIMPUTABILIDADE. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA

FUNDADA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 149 DO CPP.

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE

DEFESA. DISPENSA DA OITIVA DE TODOS OS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE.

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500079-79.2018.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500079-79.2018.8.26.0613

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2027989/2018 - DEL.POL.TAMBAU, 1165310 - DEL.POL.TAMBAU, 949/18/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2027989 - DEL.POL.TAMBAU, 949/18/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2027989 - DEL.POL.TAMBAU, 949/18/216 - DEL.POL.TAMBAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON DONIZETTI SILVA FARIA DE AQUINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

CLAYTON DONIZETTI SILVA FARIA DE ALQUINO, qualificado nos autos à fl.16, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 03 de agosto de 2018, por volta das 18h30min, nas dependências do "Supermercado Gricki", situado na Avenida José Gatto, n.º 1.262, Bairro Centro, neste município e comarca de Tambaú - SP, subtraiu, em proveito próprio, cinco barras de chocolate "Diamante Negro", avaliadas em R\$ 34,95, pertencentes ao patrimônio da empresa "Supermercado Gricki Ltda. Consta da denúncia que "o denunciado adentrou nas dependências do "Supermercado Gricki" e, lá, subtraiu as barras de chocolate descritas e ocultou-as em uma

mochila. Nesse ato foi avistado por funcionários do estabelecimento comercial, os quais acionaram a Polícia Militar. Eventualmente, o denunciado conseguiu evadir-se das dependências do supermercado sem passar pelo caixa para pagamento, mas, quando se encontrava no estacionamento de veículos, foi abordado pelo Policial Militar que atendeu ao chamado, sendo detido na posse da res. Nessa ocasião, o denunciado aludiu que tinha R\$ 6,00 e iria pagar pelas barras de chocolate que subtraiu."

A denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2018 (fl. 61).

O réu foi citado (fl.72) e ofereceu resposta à acusação (fls. 79/85).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, a seu turno, pleiteou a absolvição do acusado, alegando a aplicação do princípio da insignificância.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO FURTO

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

Como já pacificado pela Jurisprudência, a teoria utilizada para definir a consumação do crime de furto é a amotio.

A consumação ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima. Quando se diz que a coisa passou para o poder do agente, isso significa que houve a inversão da posse. Por isso, ela é também conhecida como teoria da inversão da posse. Vale ressaltar que, para esta corrente, o furto se consuma mesmo que o agente não fique com a posse mansa e pacífica. A coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima (inversão da posse), mas não é necessário que saia da esfera de vigilância da vítima (não se exige que o agente tenha posse desvigiada do bem).

Quanto a pretensão acusatória, esta merece acolhida, uma vez que os elementos de convicção trazidos aos autos demonstram com clareza a confluência de todas as elementares, bem delineada a autoria delitiva.

A testemunha Wellington Fernandes dos Reis, representante da empresa vítima, ouvido como testemunha, disse que não lembra dos fatos. Disse que é gerente. Disse que é comum o furto no supermercado.

A testemunha João Francisco Duarte Filho, Policial Militar, disse que foi contatado

por funcionário do supermercado, informando que o réu teria subtraído chocolates. Disse que na mochila do réu havia cerca de 4 mochilas de chocolate. Disse que foi contatado por Wellington Fernandes dos Reis. Disse que o réu era conhecido. Disse que acredita que o réu é usuário de droga. Disse que o produto foi restituído. Conta que o representante da vítima reconheceu de pronto. Em seu interrogatório, o réu disse que o fato é verdadeiro. Disse que teria entrado para comprar bebida alcoólica. Disse que é usuário de droga. Conta que está trabalhando. Informa que ainda é usuário de entorpecentes.

Do Princípio da Insignificância

Na análise da tipicidade, não basta apenas a subsunção do fato a norma, o que se denomina tipicidade formal, é imprescindível que haja também tipicidade material, ou a presença de um desvalor da conduta e do resultado.

É preciso interpretar o tipo penal a partir dos princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade, a fim de que o Direito Penal apenas se ocupe das condutas que forem significativamente ofensivas aos bens jurídicos protegidos. Neste conflito, surge o princípio da insignificância como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, porquanto restringe o âmbito de incidência da lei penal incriminadora e afasta a tipicidade penal.

A aplicação do princípio da insignificância, desenvolvido por Claus Roxin na década de 1970, ganhou contornos próprios na doutrina e jurisprudência brasileira. Devendo ser observada a tradição jurídica que construiu o princípio e sua evolução pelos Tribunais, o que permite a sua aplicação conforme a realidade do momento em que a infração é praticada.

A noção clássica da antijuridicidade material, proposta por Liszt, relacionava-se a conduta humana que causa lesão ao bem ou ao interesse tutelado pela norma. Esse conceito, segundo a doutrina moderna, passou a integrar a tipicidade (especificamente transformando-se em tipicidade material), desenvolvendo novos contornos.

A tipicidade é composta da tipicidade objetiva e da tipicidade subjetiva. Na primeira, encontra-se a subdivisão entre a tipicidade formal (subsunção do fato a norma) e a tipicidade material (análise do desvalor da conduta e da lesão causada ao bem jurídico protegido pela norma).

O princípio da insignificância passa a ser utilizado como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, limitando o âmbito de incidência da lei penal incriminadora, afastando a tipicidade material, quando não há na hipótese o desvalor da conduta ou do resultado.

Há relação direta com o fato típico, analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal.

O Supremo Tribunal Federal, na tentativa de sistematizar a matéria, construiu quatro vetores para sua aplicação, consistindo na mínima ofensividade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica provocada, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, ausência de periculosidade social da ação.

No caso dos autos, não se pode falar em ausência de periculosidade social tendo em vista a extensa certidão de antecedentes denotando-se a reiteração criminosa considerável, o que denota, inclusive, maior grau de reprovabilidade da conduta. Nesta linha de inteligência não é possível desconsiderar a prática delitiva apenas observando o valor da coisa subtraída, mas o contexto e o histórico do réu. Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

Do furto privilegiado

Na análise da figura privilegiada, vê-se que a lei exige ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada. Configurado o privilégio, abrem-se três possibilidades: substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuição de um a dois terços da pena ou aplicação somente da pena de multa. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do furto privilegiado, além da primariedade do réu, o valor do bem subtraído não deve exceder à importância

correspondente ao salário mínimo vigente à época dos fatos. Não há dúvida que a coisa furta e de pequeno valor, contudo, o réu é reincidente, o que afasta o reconhecimento do privilégio.

Da inimputabilidade

A alegação de que a ré é usuário de drogas ou havia feito uso de droga antes da prática do crime não é suficiente para afastar sua culpabilidade.

A inimputabilidade decorrente da dependência de entorpecentes encontra previsão no art. 45 da Lei 11.343/06, segundo o qual "é isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento".

O art. 46 ainda dispõe que "as penas podem ser reduzidas de um a dois terços, se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento".

Como se observa dos dispositivos é necessário que ao tempo da conduta o agente estivesse com a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato prejudicada, ou mesmo com a capacidade de se autodeterminar.

A instauração do incidente exige que haja dúvida sobre a integridade mental do acusado.

O fato do réu ser dependente químico não implica, por si só, na sua inimputabilidade. A prova carreada aos autos não é suficiente para demonstrar que a dependência tenha condão de alterar sua capacidade de entendimento e de autodeterminação.

Ademais, essas circunstâncias deveriam estar presentes na data dos fatos, não havendo qualquer indício de que isso tenha acontecido.

O réu em audiência demonstra clareza em suas declarações, compreende as perguntas que lhe são formuladas, não apresentando qualquer sinal de que a dependência química produza reflexos em sua condição psíquica relativas a prática do delito anterior. Ademais, extrai-se do seu depoimento que tinha consciência da ilicitude dos fatos, tendo preferido praticado o crime porquanto não obtido êxito em prostituir-se.

Portanto, não há dúvida razoável da higidez mental do acusado, não havendo indício de que tenha ocorrido na data dos fatos, razão pela qual o incidente de insanidade mental não deve ser instaurado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INIMPUTABILIDADE. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 149 DO CPP. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DA OITIVA DE TODOS OS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. REGULARIDADE. "CONFISSÃO" EXTRAJUDICIAL. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. Dessa leitura, depreende-se que o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado. 2. Neste feito, as instâncias ordinárias não identificaram dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado e, ademais, a defesa se limitou a afirmar que o réu fazia uso de entorpecentes, sem delimitar eventual dúvida a respeito da sua capacidade de entender a ilicitude ou de direcionar sua vontade, ao tempo dos fatos. 3. Visto que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a desnecessidade do exame de sanidade mental solicitado pela defesa, a alteração desse juízo demandaria o

revolvimento do material fático-probatório, expediente vedado na via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 5. A instância de origem pôde identificar todos os requisitos essenciais à regularidade da peça acusatória inicial, que atendeu plenamente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em inépcia da denúncia. 6. É legítimo o indeferimento motivado da oitiva de testemunhas, o que não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade o critério norteador do juízo de pertinência e relevância. 7. Nos termos do art. 186, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 5º, LXIII, da Constituição, o alerta sobre o direito ao silêncio é garantido ao preso e ao acusado de uma prática delitiva. A jurisprudência desta Corte Superior, no entanto, pacificou o entendimento de que a inobservância dessa regra gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende inexoravelmente da demonstração do prejuízo por quem o alega. 8. No caso em análise, o recorrente não logrou demonstrar o prejuízo suportado em seu direito de ampla defesa ante à alegada falta de advertência da prerrogativa de permanecer calado, quando da abordagem policial. É que, como consignado no acórdão recorrido, após a prisão, foi devidamente informado acerca de seus direitos constitucionalmente garantidos, conforme comprova o termo de interrogatório indiciário de fl. 07 (e-STJ fl. 409). Ressalte-se, ainda, que as declarações prestadas aos policiais no momento da prisão em flagrante serviram apenas como mais um elemento, dentro do conjunto probatório constante dos autos. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no Resp 1503533/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMA APRECIADO EM IMPETRAÇÃO CONEXA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme jurisprudência reiterada deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental está afeta à discricionariedade do magistrado, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do réu, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal. Tendo as instâncias de origem decidido pela ausência de indícios e, portanto, pelo indeferimento da perícia, resta inviável, nesta assentada, concluir em sentido diverso, tendo em vista a impossibilidade de revolvimento do arcabouço fático probatório no veio restritivo e mandamental do habeas corpus. 2. A adequação do regime inicial de cumprimento de pena já fora objeto de apreciação em habeas corpus conexo, restando consignado o acerto na fixação do equipamento fechado, tendo em vista o quantum da pena, a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente. 3. Ordem denegada. (HC 395.847/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

Ausentes causas de exclusão da ilicitude. A acusada era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa. Portanto, culpável. A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de furto, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de (1) dois a (4) oito anos, e multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à DOSIMETRIA DA PENA nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP. Primeira etapa. A culpabilidade é normal a espécie. O acusado ostenta maus antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. Não há comportamento da vítima a ser valorado. Portanto, fixo a pena base em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias multa. Segunda etapa. Presentes a causa de diminuição de pena da confissão e da agravante da reincidência, devem ambas serem compensadas. Portanto, mantenho a pena fixada na primeira fase. Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena..

Desta forma, resta a pena final de 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: ABERTO

Diante do montante da pena arbitrada, em que pesa a reincidência, diante do decurso do tempo e do retorno do réu ao convívio social buscando restabelecer laços e desenvolver atividade produtiva, mostra-se suficiente a fixação do regime aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): POSSIBILIDADE.

A pena aplicada é inferior a quatro anos, não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Em que pese tratar-se de réu reincidente em crime doloso contra o patrimônio, mostra-se suficiente a substituição da pena pela prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CLAYTON DONIZETTI SILVA FARIA DE AQUINO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do código penal, a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa no regime aberto, substituído pelas penas de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), expeça-se certidão de honorários, em caso de defesa pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Comunique-se a vítima.

P.R.I.C.

Tambaú, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA